

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E
INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA**
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

499

Arbitraje seguido entre

"CONSORCIO W&Y "

(DEMANDANTE)

Y

"MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 03-2016

LAUDO ARBITRAL

PRESIDENTE: ABG. TEODOMIRO PELAYO BETETA VENTURA

MIEMBRO: ABG. BERLY SIMON ALCANTARA ASENCIOS

MIEMBRO: ABG. PEDRO GONZALES SALDAÑA

TRIBUNAL ARBITRAL

Abog. Víctor Walter Cisneros Alvarado

Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO OF: 03-Huanuco

Huánuco, octubre - 2016

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690-962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: zelaya.20@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com

[Handwritten signature]

498

LAUDO DE DERECHO

TRIBUNAL ARBITRAL:

Abog. TEODOMIRO PELAYO BETETA

Abog. PEDRO GONZALES SALDAÑA

Abog. BERLY SIMON ALCANTARA SALDAÑA

DEMANDANTE:

CONSORCIO W&Y

DEMANDADO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

SECRETARIO ARBITRAL:

Abog. VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO

Resolución N° 13-2016-TPBV-BSAA-PGS-TA

Huánuco, 05 de octubre de 2016.

I. CUESTIÓN SOMETIDA A ARBITRAJE:

I.1. ANTECEDENTES:

Con fecha 09 de diciembre del 2013, la Municipalidad Provincial de Huánuco y el CONSORCIO W&Y, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2013-MPA, para la Ejecución de Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO-HUÁNUCO", por un monto ascendente a la suma de S/. 3'413, 794,55 (Tres millones cuatrocientos trece mil setecientos noventa y cuatro con 55/100 nuevos soles), incluye IGV, por un plazo de 240 días calendarios; refiriéndonos en adelante a este contrato como el "Contrato de Ejecución de Obra"

I. 2. CONVENIO ARBITRAL:

En la cláusula Décimo Octava del Contrato de Ejecución de Obra, se refiere a la solución de controversias, estableciendo lo siguiente: cualquiera de las partes tienen el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184°, 199°, 201°, 209°, 210° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

492

Facultativamente, cualquiera de las partes podrán someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...).

II. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

II.1. Mediante escrito de fecha 02 de Marzo del 2016, el CONSORCIO W&Y (en adelante únicamente Consorcio W&Y ó el contratista ó el demandante) SOLICITO EL INICIO DEL PROCESO ARBITRAL, en atención a la cláusula Decimo Octava del Contrato de Ejecución de Obra y el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, y que, evaluada por la Dirección del Centro, procedió a admitirla conforme a su Reglamento poniendo en conocimiento de la contraria e informando respecto a la designación del Abog. Pedro Gonzales Saldaña, como Árbitro designado por el Contratista.

Habiéndose corrido traslado a la Municipalidad Provincial de Ambo (en adelante la entidad ó el demandado) con la solicitud de inicio del proceso arbitral, la Entidad procedio a platear Oposición al Arbitraje y a designar al Abog. Berly Simon Alcantara Ascencios, como árbitro designado por la Entidad; procediendo ambos árbitros a la designación como Presidente del Tribunal Arbitral al Abog. Teodomiro Pelayo Beteta Ventura.

En este punto, cabe precisar que de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Arbitraje, pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho; por lo que no se puede oponer al arbitraje, si no oponer a la competencia y/o administración del Centro de Arbitraje.

De lo expuesto se colige que en el presente caso han operados las condiciones de renuncia a objetar previsto en el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje¹, máxime si no se interpuesto Excepción al momento de contestar la demanda.

II.2. El 29 de Abril del año 2016, reunidos ante las instalaciones del Centro de Arbitraje Torres

¹ Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias.

4196

y Tapia, ubicado en el Jirón 28 de Julio N° 893 segundo piso, oficina 03 de la ciudad de Huánuco, se realizó la Instalación del Tribunal Arbitral, con la presencia únicamente de la parte demandante representado por el señor Yimber Arnold Cabello Zelaya, no concurriendo la parte demandada pese haber sido debidamente notificado; procediéndose a levantar el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente de la cual se advierte lo siguiente:

1. Que, los árbitros declaran haber sido debidamente designados, que no tienen ninguna incompatibilidad o compromiso con las partes y que se desenvolverá con imparcialidad, independencia, y probidad.
2. Que, se designa al señor Paul Anthony Figueroa Bravo, como secretario del proceso, renunciando posteriormente, como se hace constar en la Resolución N° 01-2016/TPBV-BSAA-PGS-TA de fecha 12 de Mayo de 2016, siendo designado el Abog. Víctor Walter Cisneros Alvarado, como nuevo Secretario Arbitral del presente proceso.
3. Que, el presente arbitraje será Nacional y de Derecho.
4. Que, se aplicará las reglas que consten en la presente acta, y en su defecto lo dispuesto por el decreto legislativo N° 1071, y lo que establece el decreto Legislativo N°1017 su Reglamento y Modificatorias, en caso de deficiencias el Tribunal Arbitral queda facultado a aplicar las reglas de la sana critica.
5. Que, se establece como sede del presente arbitraje las oficinas del Centro de Arbitraje Torres y Tapia, ubicada en el Jirón 28 de Julio N° 893, segundo piso, oficina 03 de la ciudad de Huánuco.
6. Que, se establece el idioma español como idioma aplicable al presente proceso.
7. Que, los árbitros quedan facultados para suplir a su discreción cualquier deficiencia o vacío existente en la legislación o en el contrato, mediante la aplicación de principios generales del Derecho Administrativo
8. Que, se establece el lugar de las notificaciones y la forma de cómputo de los plazos.
9. Que, se establece la confidencialidad del proceso.
10. Que, se establece la forma como se desarrollaran las audiencias.
11. Que, se establece las reglas del proceso arbitral.
12. Que, se establecen los montos del costo del presente proceso.
13. Que, se otorga el plazo de 10 días a la demandante para que presente su escrito de demanda.

III. DEMANDA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

495

Mediante escrito de fecha 18 de Mayo del 2016, CONSORCIO W&Y presenta su demanda arbitral de LIQUIDACION DE OBRA (OBSERVACION), conforme a los siguientes fundamentos:

III.1. PETITORIOS:

- A) Se declare la nulidad y/o ineficacia en todos sus extremos, de la resolución N° 015-2016-A-MPA su fecha 15 de Enero de 2016, en la cual RESUELVE: APROBAR la liquidación de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO, con saldo a cargo del contratista por la suma de S/. 86,567.83 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 83/100 SOLES).
- B) Se declare la aprobación por consentimiento, la observación formulada por el Contratista Consorcio W&Y, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, observación hecha a la Liquidación de Obra practicada por la Municipalidad Provincial de Ambo.
- C) Se practique una nueva liquidación tomando en cuenta los antecedentes de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016.
- D) Que, se ordene a la entidad demandada pague el monto por concepto de saldo a favor del Contratista CONSORCIO W&Y la suma de S/. 200,590.43 (Doscientos Mil Quinientos Noventa con 43/100 Nuevos Soles), según observación formulada por el Contratista CONSORCIO W&Y mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, observación que ha quedado consentida y/o aprobada.
- E) Disponer que la entidad asuma los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del Tributario Arbitral, debiendo ordenar que se reembolse al demandante Consorcio W&Y.
- F) Disponer a la Entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

III.2. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA DEMANDA

DE LA PRIMERA PRETENSION: Se declara la nulidad y/o ineficacia en todo sus

extremos, de la resolución n° 015 – 2016 – A-MPA su fecha 15 de Enero de 2016.

494

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Que, a manera de premisa es preciso señalar el procedimiento realizado con el contratante sobre la liquidación de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO – HUANUCO y es como sigue.

1.1. Mediante carta n° 050-2015-YACZ/RL-W&Y con fecha de recepción 31 de octubre de 2015, mi representada presenta el expediente de liquidación final de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO – HUANUCO. (fuera de plazo)

1.2. Mediante Carta Notarial N° 001 – 2016 – MPA/GSG su fecha 18 de Enero de 2016, la Entidad notifica al contratista la resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, en la cual **RESUELVE:** APROBAR LA LIQUIDACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO – HUANUCO con un saldo a cargo del contratista por la suma de s/. 86,567.83 soles; liquidación practicada por la Entidad por cuanto al Contratista presento fuera del plazo de 60 días calendarios.

1.3. Que, en cumplimiento del artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mi representada mediante CARTA N° 01 – 2016 – CONSORCIO W&Y/RL-YACZ con fecha 29 de Enero de 2016, emite pronunciamiento OBSERVANDO la liquidación de obra practicada por la Entidad, liquidación que fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 015 – 2016 – A – MPA, su fecha 15 de Enero de 2016, para que la Entidad demandada en el plazo máximo de 15 días se pronuncia conforme a Ley.

1.4. Que mediante CARTA NOTARIAL N° 05-2016-MPA/GSG su fecha 12 de febrero de 2016, La Entidad demandada se ratifica con la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA que contiene la liquidación de obra practicada por la propia Entidad.

1.5. Finalmente, con fecha 02 de Marzo de 2016, mediante CARTA NOTARIAL N° 07-2016-CONSORCIO W&Y mi representada hace conocer a la Entidad, que la observación formulada por el contratista Consorcio W&Y ha quedado consentida.

493

SEGUNDO: Que, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 211 expresa lo siguiente.

(...)

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

TERCERO: Como vera de los medios probatorios aportados, si bien es cierto mi representada presentó la liquidación fuera del plazo hecho que nadie discute, la Entidad demandada no solo elaboró la liquidación, sino que también lo aprobó a priori, mediante resolución de Alcaldía N° 015 – 2016 – A – MPA con saldo a cargo del contratista por la suma de s/.86,567.83. (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 83/100 NUEVOS SOLES) Liquidación hecha por la Entidad, que fue observada por mi representada, para que la Entidad conforme ordene el RLCE observe, se pronuncie o en su caso no acoja las observaciones en el plazo de 15 días y emita la resolución correspondiente.

Pero que hizo la Entidad, se ratificó en su Resolución de Alcaldía N° 015 – 2016 – A – MPA su fecha 15 de enero de 2016 que aprueba la liquidación de obra, acto administrativo que transgrede al principio de legalidad y debido procedimiento contemplado en nuestra constitución política, en la ley de Procedimiento Administrativo

492

General y la Ley su Reglamento de Contrataciones del Estado, por cuanto en ningún extremo del art. 211 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, manifiesta de que, si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto (60 días) , la Entidad en idéntico plazo practicara y aprobara la liquidación de obra, es más, en ningún extremo del artículo 211 del RLCE, dice de que si una de las partes observa la liquidación presentada por la otra este debe ratificarse en su resolución anticipada de liquidación de obra, lo que dice la norma es que deberá pronunciarse sobre las observaciones formuladas o emitir la resolución correspondiente, pero después de las observaciones formuladas, no dentro de los sesenta (60) días calendarios (primera oportunidad que tiene la entidad), sino después de la observación formulada.

Como vera Honorables del Tribunal Arbitral, la Entidad demandada, ni siquiera ha tenido la amabilidad de revisar las observaciones formuladas por el suscrito contratista, máxime si tenemos en cuenta que la ley de contrataciones establece el procedimiento de liquidación de obra, garantizado el debido proceso, contemplada en el Art. 139 de nuestra Carta Magna y el debido procedimiento en el Arte. IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General que dice: *1.2. Los Administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho.*

CUARTO: Que, frente al Acto Administrativo nulo emitido por la Entidad, la Ley ha previsto lo siguiente:

Inciso 1 del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General dice:

Son vicios del acto administrativo, que causan nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Que, la contravención a las normas jurídicas es la primera causal de anulación de un acto administrativo, pues ninguna autoridad puede pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella, en el presente caso la resolución que solicito se declare su nulidad ha contravenido principalmente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, la resolución que solicito su nulidad, incurre en vicios en la regulación del procedimiento, teniendo en cuenta que un acto administrativo emitido a través de una procedimiento distinto al legalmente establecido es nulo de pleno de derecho.

291

Como vera, la resolución N° 015 - 2016 -A - MPA su fecha 15 de Enero de 2016, que ha emitido la Entidad demandada aprobando a priori la liquidación de obra, incurre en vicios que causan su nulidad de pleno derecho, por cuanto ha contravenido lo dispuesto en el Art. 139 de nuestra constitución política, al art. 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y al Art 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por no haber seguido el debido procedimiento establecido para la aprobación de la Liquidación final de obra, por lo tanto no solo ha incumplido la ley que son de estricto cumplimiento por las entidades del Estado, sino que también con dicho acto me causa detrimento económico a obligarme pagar S/. 86,567.83 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 83/100 SOLES). Por lo tanto debe declararse la nulidad y/o ineficacia en todos sus extremos, de la Resolución N° 015-2016-A-MPA su fecha 15 DE Enero de 2016.

DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: se declare la aprobación por consentimiento de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, observación hecha a la Liquidación de Obra, practicada por la Municipalidad Provincial de Ambo.

PRIMERO: El tercer y cuarto párrafo del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones expresa lo siguiente:

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. (el subrayado es nuestro).

En el caso de una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto dentro del párrafo anterior.

Siendo así, mi representada mediante Carta N° 01-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ con fecha 29 de Enero de 2016, presento la observación a la liquidación de obra, o sea observo la liquidación practicada por la Entidad, sin embargo la Entidad contratante no

se pronuncia a la observación, lo que hizo fue ratificarse en la Resolución de Alcaldía N° 015-2016—MPA su fecha 15 de Enero de 2016, resolución nulo de puro derecho, que fue aprobada a priori transgrediendo el principio de legalidad y al procedimiento, consecuentemente dejando consentir la observación formulada por el suscrito contratista.

SEGUNDO: El Reglamento es claro determinar cuándo dice:

“Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas”.

Mi representada observo la liquidación practicada por la Entidad, con saldo a favor del contratista por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES) Sin embargo la Entidad nunca se pronunció sobre nuestra observación, prueba de ello es que no existe documento alguno que acredite de que la Municipalidad Provincial de Ambo, no haya acogido las observaciones hecha por los contratistas, en tal sentido está claramente acreditado con el mérito de la CARTA NOTARIAL N° 07-2016-CONSORCIO W&Y su fecha 02 de Marzo de 2016, de que la observación hecha por el Consorcio W&Y a la liquidación practicada por la Entidad por imperio de la misma norma y que es de estricto cumplimiento ha quedado consentida y/o aprobada con las observaciones formuladas, por lo que también esta pretensión debe declararse fundada en todo sus extremos.

DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA: Que, la Entidad practique una nueva liquidación, tomando en cuenta la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016.

PRIMERO: Que, la Entidad practique una nueva liquidación, tomando en cuenta los antecedentes de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, por cuanto en dicha liquidación practicada por la Entidad, no se considera lo siguiente:

- 1.1. Los reajustes del adicional N° 01.
- 1.2. Los reajustes del adicional N° 02.
- 1.3. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 01.
- 1.4. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 02.
- 1.5. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 03.
- 1.6. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 04.
- 1.7. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 05.
- 1.8. Los intereses legales.
- 1.9. Otros gastos que no se han consignado.

SEGUNDO: Que, se tome en cuenta la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, para la nueva liquidación, por cuanto, la Entidad nunca se pronunció conforme a lo que ordena el RLCE a la observación formulada por el contratista, pese a que el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice; *"Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas"*.

Por consiguiente si no se ampara mi segunda pretensión principal, debe declararse fundada mi segunda pretensión.

DE LA TERCERA PRETENSIÓN: Se ORDENE a la Entidad demandada, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista CONSORCIO W&Y la suma de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES), según observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, observación que ha quedado consentida.

Que, mi representada dentro de los quince (15) días de recibido la liquidación de obra que fue elaborada por la Entidad, OBSERVO con saldo a favor del Contratista por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES) sin embargo la Entidad nunca se pronunció respecto a la observación formulada por el recurrente, por lo tanto no ha cumplido con lo dispuesto en la norma ni en el contrato, por lo que de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, la Administración Publica por su inacción debe asumir las consecuencias de

488

su inoperancia y desconocimiento, ya que por su silencio y el incumplimiento de seguir el procedimiento de liquidación de obra, no puede perjudicar a los administrados; en consecuencia la falta de pronunciamiento de la Entidad, en la forma que la ley ha establecido y dentro del plazo de quince (15) días, trae consigo el consentimiento y aprobación de la liquidación con las observaciones formuladas, entendiendo que esta norma es aplicada a ambas partes dentro del plazo establecido, de tal manera reitero, que el carácter de la norma la observación formulada por el contratista, sin un pronunciamiento de acuerdo a la Ley se encuentra aprobada por mandato por mandato expreso de la Ley, debiendo reconocer todos sus efectos legales como es el pao al contratista por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES). Conforme a la Carta de Pronunciamiento y Observacion a la Liquidación de obra y sus anexos de donde vislumbra los conceptos por las cuales la Entidad está en la obligación de pagar.

DE LA CUARTA PRETENSIÓN: Disponer que la Entidad asuma los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral, debiendo ordenar que se reembolse al demandante CONSORCIO W&Y.

Que, la Entidad esta en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO W&Y la suma de S/. 12, 000.00 (DOCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) por concepto de costas y/o honorarios del árbitro en el presente proceso arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Ambo, pues al haberse emitido la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA su fecha 15 de Enero de 2016, de manera temeraria y anticipada, transgrediendo el principio de legalidad y debido proceso, aprobando la liquidación de obra en su primera oportunidad, me ha obligado a recurrir a esta vía y afrontar el proceso económicamente.

DE LA QUINTA PRETENSION: Disponer a la Entidad asuma los costos (honorarios de abogados e ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciendo la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100NUEVOS SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, la Entidad está en la obligación de pagar al Contratista CONSORCIO W&Y la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100NUEVOS SOLES) más intereses por concepto de costos, esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho, ante la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA que de manera arbitraria, negligente y contrario a lo que ordena el Reglamento de la Ley de

Contrataciones, aprueba la liquidación de obra, privándome el derecho de poder objetar, observar y ser odio, prueba de ello es que lejos de pronunciarse sobre la observación hecha por mi representada a la liquidación practicada por la Entidad, solo se ratifican en un acto nulo, obligándome a recurrir a la cláusula de controversia, por culpa netamente de la Entidad, teniendo que afrontar económicamente no solo el proceso, sino de renovar las primas de las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento de la obra.

487

En tal sentido, si bien es cierto que no es necesario la presencia o firma de abogado para hacer valer mi derecho en esta vía arbitral, tampoco me prohíbe de hacerlo, más aun cuando la Entidad pretende cobrar un saldo a cargo del Contratista, que es completamente ilegal e injusto y que recorro a esta vía por responsabilidad exclusiva de la Entidad contratante, causándome daños económicos como lo viene haciendo, por lo que debe declararse fundada mi pretensión en todos sus extremos.

IV. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA ENTIDAD.

Mediante escrito de fecha 20 de junio del 2016, la ENTIDAD presento el escrito de CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL; por lo que estando a que dicho escrito respecto al extremo de contestación de demanda reúne los requisitos establecidos en el Art. 442° del Código Procesal Civil, el Tribunal Arbitral emitió la resolución N° 003-2016/TPBV-BSAA-PGS-TA, mediante el cual se ADMITIO a trámite la contestación de la demanda y da por ofrecidos los medios probatorios, los que se actuaran en su oportunidad, poniéndose en conocimiento de la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A) RESPECTO A LAS PRETENSIONES PRIMERA Y SEGUNDA: QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA EN TODOS SUS EXTREMOS DE LA RESOLUCIÓN N° 15-2016-A-MPA, QUE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE OBRA CON SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA POR LA SUMA DE S/. 86, 567.83 SOLES Y SE DECLARE LA APROBACIÓN POR CONSENTIMIENTO, LA OBERVACIÓN FORMULADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO W&Y MEDIANTE CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de enero del 2016.

Que, como se puede observar del escrito postulatorio, la parte demandante pretende

486

que el Tribunal declare nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, que resolvió aprobar la liquidación final de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO", practicada por mi representada, puesto que según indica, ha sido una aprobación a priori ya que la liquidación ha sido observada conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que se pronuncie o en su caso no acoja las observaciones en una resolución, sin embargo, señala que se ratificó la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, acto administrativo que transgrede el Principio de Legalidad y Debido Procedimiento, por tanto menciona que el acto administrativo es nulo por "incurrir en vicios en la regulación del procedimiento".

Que, sobre el particular cabe señalar que el contratista incurre en error puesto que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no menciona que la respuesta a la observación realizada debe ser necesariamente un pronunciamiento mediante una resolución. Al respecto citamos literalmente el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso de que una de las

partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver”.

Como se puede observar de la norma legal citada, en ningún extremo señala que se debe emitir una resolución, si no que se debe “pronunciarse” y se deberá hacer “por escrito”. En el presente caso, ante la negligencia de la parte demandante de haber presentado su liquidación fuera del plazo establecido en la Ley (lo cual es aceptado en su demanda), mi representada procedió a realizar la liquidación de la obra, lo cual es aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, pero mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, el representante legal del CONSORCIO W&Y presenta informe de pronunciamiento observando la liquidación de obra por la Entidad . Al respecto y conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, “pronunciarse” y “por escrito”, mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG de fecha 12 de febrero de 2016 emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Economico Local de la Municipalidad Provincial de Ambo, se da respuesta a la CARTA N° 001-2016-CONSORCIO W&Y-RL-YACZ, pronunciándose con INFORME N° 030-2016-MPA/SGS de fecha 12 de febrero de 2016, en la cual se RATIFICA A FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 015-2016-MPA, sustentando que la liquidación de obra ha sido elaborada de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicha CARTA NOTARIAL ha sido notificado al Ing. YIMBER A. CABELLO ZELAYA, Representante Legal del Consorcio W&Y y recepcionado por YACZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Que, en ese sentido, se ha cumplido con la norma legal citada líneas arriba, por lo que no se ha vulnerado el principio de legalidad ni el debido procedimiento señalado por el demandante. Al decir de dichos principios, se encuentran consagrados en el artículo IV numeral 1.1. y 1.2. de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, que establece "Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para las que les fueron conferidas. Principio de Debido Procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo". En el caso demandado, no se ha vulnerado tales principios, por cuanto mi representada ha emitido pronunciamiento respecto al informe de observación realizada por el demandante, y se ha realizado, dentro del plazo legal de quince (15) días, poniendo en conocimiento del contratista por escrito, más si se ha indicado que "la entidad comunica que cualquier discrepancia sobre la liquidación elaborada por la entidad debe seguir el procedimiento de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"; es decir mi representada ha sido respetuoso de los lineamientos procedimentales que ha establecido la ley, por lo que la sustentación en la afectación de los principios de Legalidad y Debido Procedimiento , y por ende existe vicios de nulidad son infundadas.

Ahora bien, es de indicar que de acuerdo al numeral 1.1. del artículo 1° de la Ley de Procedimiento Administrativo General –Ley N° 27444: "son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de norma de derecho público, están destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta". Como se puede, revisar de la norma legal, los actos administrativos serán las declaraciones de las entidades, la cual no necesariamente debe recaer en una resolución, conforme pretende imponer el demandante, sino que debe contener o debe producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de una situación

483

concreta. Lo cual en el presente caso, válidamente se ha expedido una CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG de fecha 12 de febrero de 2016 emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de ambo, la cual contiene la respuesta a la CARTA N° 001-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, pronunciándose con INFORME N° 030-2016-MPA/SGS de fecha 12 de febrero de 2016, en la cual se RATIFICA A FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 015-2016-MPA, esto es, de los documentos mencionados existe una consecuencia jurídica sobre la situación concreta del contratista, lo cual es totalmente valida y eficaz, porque esta resolviendo una situación concreta la misma que tendrá efectos jurídicos en el demandante. Por tanto no se advierte vicios ni causales de nulidad que puedan estar sustentadas en el artículo 10° de la Ley N° 27444, por consiguiente en INFUNDADA dichas afirmaciones por el demandante.

Que, respecto a que se declare la aprobación por consentimiento de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, es de indicar que, la misma no tiene sustento legal, ya que como se ha indicado precedentemente, mi representada ha dado respuesta a la observación realizada por el demandante, Mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG de fecha 12 de febrero de 2016, la cual contiene el INFORME N° 030-2016-MPA/SGS de fecha 12 de febrero de 2016, en la cual existe el pronunciamiento de la entidad, la cual es la RATIFICACIÓN FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 015-2016-MPA.

El análisis jurídico de la norma legal contenida en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la observación formulada por una de las partes, se advierte que contiene dos presupuestos "*que haya pronunciamiento*" y que "*sea por escrito*" lo cual en el presente caso, se ha cumplido y se ha explicado líneas arriba. El demandante confunde en que se debe responder siempre con resolución, lo cual la norma legal no regula en ese sentido, por tanto no está prohibido emitir pronunciamiento mediante otra forma distinta a la resolución, mas si consideramos un acto administrativo debe contener una declaración de la entidad, y que produzca efectos jurídicos en la situación del administrado, lo cual en el presente caso se ha dado mediante la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/SGS de fecha 12 de febrero de 2016. Por consiguiente, es totalmente infundada aprobar por

consentimiento la observación formulada por el contratista sobre la liquidación de obra realizada por la entidad, toda vez la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ (que contiene informe de observación) ha sido respondido dentro del plazo legal de 15 días establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo así con la citada norma legal. Por tanto esta pretensión principal de aprobación por consentimiento deviene en INFUNDADA, por no existir consentimiento alguno.

- B) RESPECTO A LAS PRETENSIONES SEGUNDA SUBORDINADA Y TERCERA: QUE LA ENTIDAD PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN FORMULADA EN LA CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2016 Y SE ORDENE A LA ENTIDAD PAGUE EL MONTO POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO W&Y LA SUMA DE S/. 200, 590.43.

Que, respecto a estas pretensiones demandadas, sobre practicar nueva liquidación, tomando en consideración la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y con CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, en el sentido de que la entidad no ha considerado lo siguiente:

- 1.1. Los reajustes del adicional N° 01
- 1.2. Los reajustes del adicional N° 02
- 1.3. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 01
- 1.4. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 02
- 1.5. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 03
- 1.6. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 04
- 1.7. Los mayores gastos generales de la ampliación N° 05
- 1.8. Los intereses legales
- 1.9. Otros gastos que no se han considerado

Al respecto, se debe declarar infundada la pretensión de realizar nueva liquidación, toda vez que la observación formulada mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, ha sido materia de pronunciamiento mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA-/SGS de fecha 12 de febrero del 2016, en la cual se le adjunta y remite el INFORME N° 030-2016-MPA-/SGS, de fecha 12 de febrero del 2016 que

contiene la CARTA N° 002-2016-MPA-ING-LIQ./JECT, en la cual se analiza de manera detallada la liquidación de la obra realizada por la entidad, así como la observación formulada.

Que, sin desmedro de lo indicado, debo indicar que conforme el INFORME N° 166-2016-MPA-PSMS-SGSL, de fecha 14 de junio del 2016, se advierte que el demandante solicita los reajustes del adicional y mayores gastos generales y de este inclusive respecto de una ampliación N° 05 que no se ha generado, lo cual advertimos su no existencia con el informe de observación presentada por el demandante, lo cual abiertamente denota una intención de generar un perjuicio a la entidad, de hechos que no se han dado.

El demandante en el entendido que le corresponde los mayores gastos generales, no ha considerado que según las resoluciones que aprueban las ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03 y 04 que están contenidas en la resolución de alcaldía N° 257-2014-A-MPA de fecha 15 de julio del 2014, resolución de alcaldía N° 272-2014-A-MPA de fecha 07 de agosto de 2014, resolución de alcaldía N° 361-2014-A-MPA de fecha 12 de noviembre de 2014 y la resolución de alcaldía N° 414-2014-A-MPA de fecha 24 de diciembre de 2014 respectivamente, han resuelto ampliar el plazo, pero indicando *"sin el pago de mayores gastos generales por la ampliación aprobada"*, y esto en función a sus cartas N° 017, 021, 028, 032 emitidos por el CONSORCIO W&Y.

Que, conforme al artículo 16° numeral 16.1 de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, se tiene que: "El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo", asimismo se tiene el artículo 109° numeral 109.1 de la mencionada ley que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta ley". En el presente caso, el demandante no acredita que haya cuestionado las resoluciones de ampliación de plazo N° 01, 02, 03 y 04 que están contenidas en las resolución de alcaldía N° 257-2014-A-MPA de fecha 15 de julio del 2014, resolución de alcaldía N° 272-2014-A-MPA de fecha 07 de agosto de 2014, resolución de alcaldía N° 361-2014-A-MPA de fecha 12 de noviembre de 2014 y la resolución de alcaldía N° 414-2014-A-MPA de fecha 24 de diciembre de 2014 respectivamente, en la cual se resolvió "sin el pago de mayores

gastos generales por la ampliación aprobada". En tal sentido, ha consentido con su inacción voluntaria los efectos de las mencionadas resoluciones, generándose así la renuncia.

Un aspecto esencial a tener en cuenta es el relacionado con la naturaleza patrimonial del derecho al pago de gastos generales derivados de prórroga de plazo contractual ostentado por ende el carácter de disponible y como tal su titular acorde con el principio de autonomía de la voluntad que rige los actos jurídicos puede disponer de tal derecho ejerciendo la facultad de exigirlo o como en el presente caso renunciar a el. Como es evidente lo que importa para la validez y eficacia del acto jurídico unilateral de renuncia efectuado por el representante legal de la contratista CONSORCIO W&Y, es que en el mismo hayan concurrido los requisitos de validez exigidos por el Código Civil que define el acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas requiriéndose de agente de agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

Que, la concurrencia de dichos requisitos queda plenamente demostrado en tanto que el representante legal del CONSORCIO W&Y, titular del derecho ha dejado consentir el contenido de las resoluciones que aprueban la ampliación de plazo y que a la vez resuelven "sin el pago de mayores gastos generales por la ampliación aprobada", las cuales se han emitido en función a sus CARTAS N° 017, 021, 028 y 032, emitidos por el representante legal del CONSORCIO W&Y, cabe indicar que conforme al artículo 141° del Código Civil, se establece que: "La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelen su existencia". En el presente caso. El representante del CONSORCIO W&Y se les notificó las resoluciones de ampliación de plazo N° 01, 02, 03 y 04 que están contenidas en la resolución de alcaldía N° 257-2014-A-MPA de fecha 15 de julio del 2014, resolución de alcaldía N° 272-2014-A-MPA de fecha 07 de agosto de 2014, resolución de alcaldía N° 361-2014-A-MPA de fecha 12 de noviembre de 2014 y la resolución de alcaldía N° 414-2014-A-MPA de fecha 24 de diciembre de 2014 respectivamente; sin embargo, las mencionadas no fueron cuestionadas por la vía legal que la ley les ampara, al contrario dejaron

consentir para que surtan sus efectos, hecho que denota y se infiere un despliegue de voluntad en la aceptación del contenido de la resolución (renuncia al pago de mayores gastos generales por la ampliación aprobada)-

429

Que, el artículo 143° del Código Civil establece que "Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar las que juzguen conveniente", lo que en el presente caso, se demuestra con el consentimiento desplegado por el demandante al no cuestionar las resoluciones de ampliación de plazo, ya que la norma legal en específico no regula la formalidad específica de renuncia. Es por ello, que no se debe considerar lo solicitado por el demandante respecto a los reajustes del adicional y mayores gastos generales, debiendo declararse INFUNDADA esta pretensión.

Siendo así, la tercera pretensión solicitada por el demandante, respecto a que se pague la suma de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 SOLES), es totalmente infundada, toda vez que la observación del demandante contenida en su CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de enero del 2016, carece de sustento técnico y legal, toda vez que la liquidación presentada es totalmente ajena a la realidad documentaria.

Cabe señalar que de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 166-2016-MPA-PSMS-SGSL, el liquidador externo aplicó la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, conforme al Acta de Conciliación N° 060-2015, en la cual el contratista acepta la propuesta de mi representada. En tal sentido, la liquidación de obra efectuada por mi representada contenida en la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 015-2016-MPA, se encuentra ajustada a derecho y conforme a las normativas legales al caso. En consecuencia las pretensiones del demandante son INFUNDADAS.

- C) RESPECTO A LAS PRETENSIONES CUARTA Y QUINTA: QUE, LA ENTIDAD ASUMA LOS GASTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL, ASÍ COMO LOS COSTOS, MAS LOS INTERESES LEGALES HASTA LA FECHA DE CANCELACIÓN: De conformidad con el numeral 1) del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, los costos (honorarios de abogado e ingenieros asesores) y costas (gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral) del presente proceso arbitral deberán ser asumidos completamente por el demandante, toda vez que su demanda

carece de fundamentos facticos y legales que lo amparen. Asimismo los intereses legales deben seguir la suerte del principal, debiendo el demandante cancelar a la entidad respecto a esa pretensión hasta la cancelación.

478

En este punto SOLICITO A VUESTRO DESPACHO, se condene al demandante al pago de costas y costos del proceso que se incurre, debiendo reembolsar a la entidad, en lo que corresponda.

V. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

El día 18 de julio del año 2016, a horas 16:05 de la tarde, en la sede del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de la Ciudad de Huánuco, ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 893 – Segundo Piso – Oficina 03; con la asistencia de los Árbitros, el Secretario Arbitral, el representante legal de la demandante CONSORCIO W&Y, el señor Yimber Arnold Cabello Zelaya; y el Procurador Público Municipal de Ambo el Abog. Levi Joel Aguirre Rojas; se llevó a cabo la audiencia previamente programada sobre conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios. Seguidamente y previo a proceder con el inicio de dicha audiencia el Tribunal Arbitral emitió la resolución N° 07-2016-TPBV-BSAA-PGS-TA, resolviendo el Recurso de Reconsideración deducida por la demandada, **DECLARÁNDOLA FUNDADO**, la misma que obra a folios 396 al 397; resolviendo además diversos puntos entre ellos SUSPENDER la presente audiencia a solicitud de la parte demandada hasta el 05 de agosto del 2016 a horas 16:00; llevándose a cabo la misma en la fecha señalada con la presencia del Tribunal Arbitral, el Secretario Arbitral, el representante legal del CONSORCIO W&Y el señor Yimber Arnold Cabello Zelaya; y el Procurador Público Municipal de Ambo el Abog. Levi Joel Aguirre Rojas, dándose inicio a la audiencia, conforme al siguiente desarrollo:

V.I. CONCILIACIÓN:

Habiéndose propiciado el dialogo entre las partes, a fin de que se llegue a un acuerdo conciliatorio y no siendo posible porque ninguna de las partes presento propuestas conciliatorias en este acto; las partes tienen la posibilidad de llegar a una conciliación total o parcial en cualquier momento del proceso arbitral, siendo así se procedió con el trámite del proceso.

V.II. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Tribunal Arbitral en consenso con las partes procedieron a fijar los siguientes puntos controvertidos, haciendo la precisión de que las características y la acumulación de las pretensiones propuestas serán analizadas en el laudo:

Primer punto controvertido:

Se declare la nulidad y/o ineficacia en todos sus extremos de la resolución N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2016; documento que resuelve aprobar la liquidación de la obra "Mejoramiento de los servicios municipales de la Municipalidad de Ambo - Provincia de Ambo - Huánuco", con saldo a cargo del contratista por un monto de S/. 86,567.83 (Ochenta y seis mil quinientos sesenta y siete con ochenta y tres 00/100 soles).

Segundo punto controvertido:

Se declare la aprobación por consentimiento de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante carta N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de enero del 2016, observación hecha a la liquidación de obra practicada por la Municipalidad Provincial de Ambo

Tercer punto controvertido:

Pretensión subordinada: se practique una nueva liquidación, tomando en cuenta los antecedentes de las observaciones formuladas por el contratista consorcio W&Y, mediante carta N° 01-2016.consorcio W&Y/RL-YACZ, del 29 de enero del 2016

Cuarto punto controvertido:

Si corresponde ordenar a la entidad demandada por concepto de saldo a favor del contratista W&Y, la suma de S/. 200,590.43 (doscientos mil quinientos noventa con cuarenta y tres 00/100 soles), según observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y, mediante carta N° 01-2016.CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de enero del 2016, observación que ha quedado consentida y/o aprobada.

Quinto punto controvertido:

Disponer que la entidad asuma los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral, debiendo ordenar que se reembolse al demandante consorcio W&Y, por la suma de 12,000.00 (doce mil y 00/100 soles).

Sexto punto controvertido:

Disponer que la entidad asuma los costos de honorarios de Abogados e Ingenieros asesores) para la defensa del presente proceso arbitral por la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles) a favor del contratista Consorcio W/Y.

476

VI. ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS:

Acto seguido el Tribunal Arbitral, procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos por las partes.

VI.1. DE CONSORCIO W&Y:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos y que se encuentran identificados en los anexos 1-A al 1-J de su escrito de demanda.

VI.2. DE LA ENTIDAD:

Se admiten los medios probatorios ofrecidos y que se encuentran identificados en los anexos 1-A y 1-I de su escrito de contestación de demanda.

VII. ALEGATOS ESCRITOS Y PLAZO PARA LAUDAR:

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se dispuso otorgar el plazo de (03) días a las partes, a fin de que presenten sus alegatos escritos, y de considerarlo necesario solicitar audiencia de informes orales.

Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2016, la Entidad cumplió con presentar sus alegatos escritos y solicito audiencia de informes orales.

Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2016, la Demandante cumplió con presentar sus alegatos escritos.

Por último, estando a que la Entidad solicito la celebración de una audiencia de informes orales, mediante resolución N° 009-2016/TPBV-BSAA-PGS-TA, se admitió los alegatos escritos presentadas por las partes y programo la audiencia de informe oral para el día 24 de agosto de 2016 a horas 17:30 pm, la misma que fue suspendida llevándose a cabo recién el

478

día 02 de setiembre del 2016 a horas 17:40 pm, la misma que se realizó en las instalaciones del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia. Posteriormente mediante resolución N° 012-2016/TPBV-BSAA-PGS-TA, se OTORGO el plazo de 15 DIAS HABLES a fin de que el TRIBUNAL ARBITRAL emita el LAUDO respectivo.

VIII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA:

En el numeral 4 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, se estableció que será aplicable al presente proceso arbitral, las reglas establecidas en el Acta de Instalación, el Decreto Legislativo N° 1071 ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Ley que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; estableciéndose asimismo que en caso de deficiencia o vacíos existentes las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo, y de acuerdo a las reglas de la sana critica.

IX. ANALISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA.

CUESTIONES PRELIMINARES:

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar la siguiente: 1) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas establecidas en el Acta de Instalación, el Decreto Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Ley que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje; estableciéndose asimismo que en caso de deficiencia o vacíos existentes las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo, y de acuerdo a las reglas de la sana critica. 2) Que, CONSORCIO W&Y presento su demanda en el plazo establecido y ejerció plenamente su derecho de defensa. 3) Que, la Municipalidad Provincial de Ambo- Huánuco, fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa. 4) Que, las partes tuvieron plena oportunidad de ofrecer y actuar todos sus medios probatorios 5) Que, el Tribunal Arbitral ha procedido a laudar dentro del plazo legal establecido.

XI. ANALISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

I. EMISION DEL LAUDO ARBITRAL

- 474
1. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse respecto de cada uno de puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de las pruebas actuadas en el arbitraje, para determinar en base a la valoración conjunta de ellas, así como los fundamentos expuestos por cada parte, las consecuencias jurídicas que de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que se haya probado en el marco del arbitraje.
 2. Debe destacarse que según HUGO ALSINA² el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.
 3. Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que "la actividad probatoria no pertenece a quién la realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independiente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó."³
 4. Asimismo, debe tenerse en cuenta que "en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las

² ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

³ TARAMONA H. José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, Pág. 35.

partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional".⁴

473

5. Es así, que respecto a los sistemas de valoración de la prueba, la doctrina mayoritaria, ha adoptado el sistema de la libre valorización de los medios de prueba –o de la sana crítica–, en virtud de la cual “el juzgador tiene la libertad para valorar los medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley, pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el Derecho y las máximas experiencias aplicables al caso”⁵.
6. En palabras de FERNÁNDEZ ROZAS, “es una facultad que exige a los árbitros un ejercicio racional y lógico y que en ningún caso puede tener un cariz arbitrario; esto es la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas “reglas de la sana crítica”, que no han de entenderse como un pretexto para al abuso, sino que presuponen que, una vez analizadas las circunstancias específicas, el árbitro debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual, la prueba es idónea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas referencias lógicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen la posible parcialidad o arbitrariedad del árbitro”.⁶
7. Finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los medios probatorios aportados y ordenados de oficio, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.
8. Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

⁴ FERNÁNDEZ ROZAS. “Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina”. Volumen II. Ed. Iustel, 2008, Pág. 756.

⁵ CASTILLO FREYRE, Mario. “Arbitraje y Debido Proceso”. Ed. Palestra, 2007. Pág. 315.

⁶ Ídem. Pág. 757.

- 472
9. En tal sentido, el Tribunal Arbitral procede a pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos. Sobre esto último, es menester señalar que el orden fijado en el Acta de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Actuación de Medios Probatorio es meramente referencial (tal como se hizo reserva de ello), por lo que el Tribunal Arbitral ha visto por conveniente variar el orden indicado.

SEGUNDA PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI ES PROCEDENTE DECLARAR PROCEDENTE LA APROBACIÓN POR CONSENTIMIENTO DE LA OBSERVACIÓN FORMULADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO W&Y, MEDIANTE CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2016, OBSERVACIÓN HECHA A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRACTICADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO.

10. Que, del acto administrativo materia de cuestionamiento, se advierte que con fecha 31 de agosto de 2015, se procedió a hacer la recepción física de la obra, por lo cual el plazo de presentación de la liquidación de obra por parte del contratista ha sido en fechas (01/09/2015 a 30/10/2015); empero el contratista ha presentado la liquidación de la obra con fecha 18 de noviembre del 2015 en el plazo, es decir, fuera del plazo que establece el artículo 211° que establece Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que es de 60 días; por lo que la Entidad procedió a realizar la liquidación.
11. Al respecto, en el presente caso nos encontramos en el supuesto conforme al segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento *ad litteram* prescribe:

"Artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra

(...)

Si el contratista no presentara la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibida la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación o arbitraje.

(...)"

12. En tal sentido, *prima facie*, se desprende que la Entidad dentro de los sesenta (60) días contados desde el vencimiento de la fecha que tenía para presentar la liquidación el Contratista, ha cumplido con elaborar la Liquidación de Obra mediante la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2016, resolviendo en su artículo primero aprobar la liquidación de la obra con sus características; en su artículo segundo ha resuelto aprobar, el saldo a cargo del Contratista de S/. 86, 567. 83 (Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete con 83/100 Nuevos Soles; y, en su artículo tercero ha resuelto aprobar la penalidad por mora en la ejecución de la prestación que corresponde al monto de S/. 356, 276. 20 nuevos soles (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis con 20/100 Nuevos Soles).
13. Que, conforme se puede colegir la controversia se encuentra configurado por una cuestión, si se quiere, formal. Ahora bien para determinar ello, se hace necesario verificar si las partes han cumplido con realizar las actuaciones pertinentes dentro de los plazos legalmente previstos. Es precisamente en este punto donde surge la controversia materia del presente proceso.
14. En tal sentido, aquí lo que se está discutiendo es si la liquidación practicada y aprobada por la Entidad a través de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2015, habría sido realizado sin que cumplir el procedimiento regular establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que se encontraría incurso en causal de nulidad.

470

15. Ahora bien, hay que precisar que las Entidades por antonomasia dentro de su autonomía administrativa emiten normas, como son los actos administrativos, y materia de contrataciones del Estado para regular cuestiones contractuales; en ese sentido, al no haber presentado la liquidación dentro del plazo establecido en el artículo 2011 del Reglamento por parte del Contratista, la Entidad ha elaborado la liquidación, a través de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2015, mediante el cual se aprueba liquidación practicada por la Entidad. Ante dicho acto de aprobación de Liquidación Final de Obra practicado por la Entidad correspondía al Contratista de acuerdo al dispositivo legal citado, realizar un pronunciamiento en un solo sentido: OBSERVAR la liquidación presentada por la Entidad; y, la Entidad, por su parte pronunciarse ya sea acogiendo o no las observaciones por escrito. En tal sentido, corresponde analizar si ello realmente ha sucedido así.

16. Al respecto, y siguiendo el criterio establecido en la Opinión N° 104-2013/DTN, emitido por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), y tal como ya se precisó en el numeral anterior de del presente laudo, en el escenario que se tiene, correspondía al Contratista, conforme el artículo 211° del Reglamento emitir un pronunciamiento: OBSERVANDO la liquidación presentada por la Entidad, como en efecto ha sido realizado mediante Carta N° 01-2016=CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de enero de 2016, el mismo que ha sido recepcionado por la Entidad con la misma fecha. Ante ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211° del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, la Entidad por su parte debía pronunciarse ya sea acogiendo o no las observaciones por escrito; en tal sentido, la Entidad mediante Carta Notarial N° 05-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de febrero de 2016, la Entidad demandada se ha ratificado con la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA, que contiene la liquidación de obra practicada por la Entidad, es decir, se ha pronunciado por escrito no acogiendo las observaciones formuladas por el Contratista. No obstante, si bien la norma no establece que una vez que se ha observado la liquidación practicada por la Entidad ésta se pueda "ratificar" de ella; empero ello tampoco significa que se esté consintiendo, ya que la norma establece que debe haber un pronunciamiento por escrito, y como se ha venido sosteniendo la Entidad se puede pronunciar (ya sea acogiendo o no las observaciones), mediante actos administrativos o actos de administración, por excelencia como es el Informe N° 030-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de febrero del 2016, mediante el cual se ratifica el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA, de fecha 15 de enero del

2016; en consecuencia, no existe violación del debido procedimiento, es decir, el procedimiento regular establecido en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en este extremo, no encontrándose incurso en causal de nulidad establecida en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD Y/O INEFICACIA EN TODOS SUS EXTREMOS DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 015-2016-A-MPA, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016.

17. Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2016, resolviendo en su artículo primero aprobar la liquidación de la obra con sus características; en su artículo segundo ha resuelto aprobar, el saldo a cargo del Contratista de S/. 86, 567. 83 (Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete con 83/100 Nuevos Soles; y, en su artículo tercero ha resuelto aprobar la penalidad por mora en la ejecución de la prestación que corresponde al monto de S/. 356, 276. 20 nuevos soles (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis con 20/100 Nuevos Soles).
18. Que, sobre el presente punto controvertido, la eficacia y/o la validez legal del acto administrativo, que si bien se encuentra relacionado si se ha seguido el procedimiento establecido en el Art. 211° del Reglamento, el mismo que ya ha sido analizado por el Tribunal Arbitral; sin embargo, aunque no ha sido alegado como causal de nulidad por el Contratista, en aplicación del principio *iura novit curia*, regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, se procederá a analizar si de los fundamentos de hecho alegado por el Contratista en el fundamento sobre la segunda pretensión subordinada es causal de nulidad, que la Entidad no consideró los reajustes del adicional N° 01, los reajustes del adicional N° 02, los mayores gastos generales de la ampliación de plazo N°s. 01, 02, 03, 04, 05, los intereses legales y otros gastos que no se han considerado.
19. Que, al respecto se debe tener en consideración que de acuerdo al criterio establecido en la Opinión N° 104-2013/DTN, sobre el contenido de la liquidación de obra en el punto 1.1: "Así, la liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la

prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de las partes".

En ese sentido, se advierte del fundamento b.2.4 que mediante resoluciones aprueban las Ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03 y 04 que están contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 257-2014-A-MPA, de fecha 15 julio de 2014, la Resolución de Alcaldía N° 272-2014-A-MPA, de fecha 07 de agosto de 2014, la Resolución Alcaldía N° 361-2014-A-MPA, de fecha 12 de noviembre de 2014 y la Resolución de Alcaldía N° 414-2014-MPA, de fecha 24 de diciembre de 2014, respectivamente han resuelto ampliar el plazo, pero indicando "sin el pago de mayores gastos generales por la ampliación aprobada", debido a la renuncia de gastos generales efectuado a mérito de sus Cartas N° 017-021-028, 031 por el Consorcio W&Y.

Debe precisar que los párrafos primero y segundo del artículo 202° del Reglamento regulan los efectos de la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra, conforme a lo siguiente: "Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra. Y agrega en su segundo párrafo: "Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso." (El resaltado es agregado).

En esa línea de ideas, en la Opinión N° 012-2014/DTN, en el punto 2.2, sobre los renunciabilidad de gastos generales ha establecido:

"(...)

Al respecto, debe señalarse que el pago de los mayores gastos generales tiene por objeto reconocer los mayores costos indirectos que asume el contratista como consecuencia del incremento del plazo de ejecución de la obra por causas ajenas a su voluntad, evitándose, de esta manera, la afectación del equilibrio económico de las prestaciones asumidas por

467

las partes, en aplicación de lo dispuesto por el Principio de Equidad⁷, el mismo que establece que "Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad (...)". (El subrayado es agregado).

Sin perjuicio de ello, toda vez que el derecho a cobrar los mayores gastos generales originado por la aprobación de una ampliación de plazo es un derecho de crédito del contratista y, en consecuencia, de su libre disposición, este podría renunciar⁸ al mismo, una vez aprobada la ampliación del plazo; máxime si la normativa de contrataciones del Estado no ha prohibido tal renuncia⁹, ni se vulnera alguna norma imperativa o de orden público.

En esa medida, el contratista, libre y voluntariamente, sin que exista coerción¹⁰ o algún vicio al manifestar su voluntad¹¹, puede renunciar al pago de los mayores gastos generales variables.

De conformidad con lo expuesto, aun cuando la Entidad está obligada a pagar oportunamente al contratista los mayores gastos generales una vez aprobada una ampliación del plazo de un contrato de obra, el contratista puede renunciar a este derecho libre y voluntariamente con posterioridad a la aprobación de la ampliación de plazo, en tanto constituye un derecho patrimonial de libre disposición."

Empero, en el presente caso, se advierte que la renuncia ha sido antes de la aprobación de plazo, no pudiéndose aseverar que dicha renuncia haya sido libre y voluntaria, el proceder de la Entidad constituye un ejercicio abusivo del derecho, y que de conformidad a lo establecido en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, la Ley no ampara.

En cuanto a los reajustes de los adicionales N°s 01 y 02, las mismas que habrían sido aprobadas mediante Resolución de Alcaldía N° 231-2014-A-MPA y Resolución de Alcaldía N° 414-2014-A-MPA, que no ha sido contradicho por la Entidad, estos reajustes se habría calculado

⁷ Definido por el literal l) del artículo 4 de la Ley.

⁸ En este punto, debe señalarse que si bien **la renuncia** no está regulada expresamente en el Código Civil, la doctrina la define como "(...) un acto unilateral, ejercitado sólo por el acreedor de la relación obligacional, pues si contara con el asentimiento oportuno del deudor -sin dejar de encontrarnos dentro del campo de la renuncia- se trataría de una condonación." A su vez, de conformidad con el artículo 1295 del Código Civil, la doctrina también señala que "Condonar es perdonar una deuda o, en expresiones distintas, renunciar a un crédito, con la amuencia del deudor. Así, cuando el acreedor perdona una deuda y el deudor conviene en ello, se extingue la obligación a cargo de este último." (El subrayado es agregado). OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de las obligaciones, Vol. XVI, Tercera Parte, Tomo IX, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, Segunda Edición, págs. 263 y 245.

⁹ Este criterio se sostiene en lo expresado en el literal a) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que señala expresamente que "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, **ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe**". (El resaltado es agregado).

¹⁰ Según el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, "coerción", en su primera acepción, significa "Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta". <http://lema.rae.es/drae/?val=coacci%C3%B3n>

¹¹ De conformidad con los artículos 201 y siguientes del Código Civil.

466

sin tener en cuenta el cálculo del Anexo 1 de las observaciones planteadas en la Carta N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ. Al respecto, este se encuentra normado en el artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe considerar que el reajuste de las valorizaciones tiene por objeto actualizar el valor de los elementos que intervienen en la ejecución de una obra a la fecha correspondiente al mes de pago de la valorización, la aplicación del coeficiente de reajuste "K" sobre cada valorización puede generar un derecho de crédito en el contratista o en la Entidad, en función a si los índices con los cuales se calcula dicho coeficiente se han incrementado o reducido; por lo que la Entidad debe proceder a verificarlos, conforme se encuentra peticionado por el Consorcio.

En cuanto a los intereses legales, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, regulan el pago de interés de ciertos conceptos, por lo que de ser el caso la Entidad debe reconocerlos desde la fecha de devengue conforme a Ley.

En este punto se ha de precisar, que el Consorcio ha solicitado también el pago de otros gastos. Al respecto, se debe precisar que el Consorcio no ha precisado qué conceptos serían, por lo que no habiéndolos probados, no resulta procedente, ya que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Por las razones antes expuestas con la emisión del acto administrativo materia de cuestionamiento se ha vulnera el principio de legalidad al no haber considerado lo establecido en el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y motivado debidamente, constituye un acto administrativo que no se encuentra debidamente justificado; por cuanto, in prima facie, se puede colegir que conforme se ha explicado en líneas precedentes no se ha procedido conforme a la Opinión N° 012-2014/DTN y Opinión N° 104-2013/DTN; el accionar de la autoridad administrativa constituye una violación flagrante del principio de legalidad, que establece que las autoridades deben actuar con respecto a la Constitución, a Ley y normas reglamentarias; consecuentemente se encuentra inmerso en causal de nulidad y/o ineficacia conforme lo dispone el numeral 1) y 2) del artículo 10° de la Ley N° 27444, es por ello que se debe declarar fundado la demanda en este extremo.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN TOMANDO EN CUENTA LOS ANTECEDENTES DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS

20. Que, conforme a lo expuesto al analizar el primer punto controvertido sobre la nulidad y/o ineficacia de la resolución que aprueba la liquidación de obra, se debe amparar en parte la presente pretensión; en consecuencia, la Entidad debe practicar una nueva liquidación considerando los mayores gastos generales de la ampliación de plazo N°s. 01, 02, 03, 04; verificar los reajustes del adicional N° 01, los reajustes del adicional N° 02, más los intereses legales de corresponder.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD DEMANDADA POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA W&Y, LA SUMA DE S/. 200, 590. 43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES), SEGÚN OBSERVACION FORMULADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO W&Y, MEDIANTE CARTA N° 01-2016. CONSORCIO W&YRL-YACZ, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2016, OBSERVACIÓN QUE HABRÍA QUEDADO CONSENTIDA.

21. Que, conforme a lo expuesto la pretensión de consentimiento de la observación formulada por el Consorcio de la liquidación final de obra practicado por la Entidad no ha quedado consentido; en consecuencia, no corresponde ordenarse el pago del monto precisado en su pretensión contenido en el escrito de su demanda, ascendente a la suma de S/. 200, 590. 43 (Doscientos Mil Quinientos Noventa con Cuarenta y Tres con 00/100 nuevos soles).

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI LA ENTIDAD DEBE SUMIR LOS GASTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL, ESTO ES GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, DEBIENDO ORDENAR QUE SE REEMBOLSE AL DEMANDANTE CONSORCIO W&Y, POR LA SUMA DE S/. 12, 873. 67 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 67/100 SOLES).

22. Que, de conformidad con el artículo 70° y numeral 1) del artículo 72° de la Ley de Arbitraje, los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos arbitrales. Asimismo, de conformidad con el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo, los árbitros deben tener presente, de ser el caso, el acuerdo de las partes; además tal norma legal establece que a

464
falta de acuerdos sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, los árbitros podrán distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

23. En el caso de autos se tiene que en el Acta de Instalación se ha establecido que los costos del arbitraje serían asumidos en forma proporcional por ambas partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
24. Que, en el presente caso, se tiene que se ha establecido el costo total del presente arbitraje, la suma de S/. 12, 873. 67 (Doce Mil Ochocientos Setenta y Tres con 67/100 soles); monto que debía ser cancelado por ambas partes en forma proporcional al cincuenta por ciento cada uno; sin embargo, si bien el único que ha realizado el pago es el demandante, incluso subrogándose en la parte que le correspondía a la Entidad. En este contexto, este Tribunal Arbitral Unipersonal, estima que el costo del presente proceso arbitral deben ser asumidas por cada parte; en consecuencia, la Entidad debe reembolsar a favor del Consorcio la suma de S/. 6, 436. 83 (Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 83/100 Nuevos Soles).

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE QUE LA ENTIDAD ASUMA LOS COSTOS DE HONORARIOS DE ABOGADOS E INGENIEROS ASESORES) PARA LA DEFENSA DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL POR LA SUMA DE S/. 8, 000. 00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES).

25. Que, al respecto se advierte que el Consorcio no ha adjuntado medio probatorio alguno que acredite su pretensión, máxime si como el mismo demandante menciona que su demanda no lleva la firma de letrado en derecho, así también la de ingeniero; por lo que no habiéndolos probados, no resulta procedente, ya que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.
26. Que, luego del desarrollo de cada una de las pretensiones planteadas en la demanda y en la reconvencción, corroboradas en los puntos controvertidos fijados, y en mérito de los medios probatorios que corren en autos que han sido valorados en conjunto, el tribunal arbitral lauda de la siguiente manera:

PRIMERO.- Al Primer Controvertido: Se declara **FUNDADA**, por lo que se **DECLARA** la **NULIDAD** de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de enero del 2016.

SEGUNDO.- Al Segundo Controvertido: Se declara **INFUNDADA**, por lo que se **DECLARA NO APROBADO** por consentimiento de la observación formulada por el contratista Consorcio W&Y.

TERCERO.- Al Tercer Punto Controvertido: Se declara **FUNDADA EN PARTE**; en consecuencia **SE ORDENA** a la Municipalidad Provincial de Ambo practicar una nueva liquidación en el plazo de sesenta (60) días calendarios, a partir del día siguiente de la notificación del presente Laudo Arbitral, considerando los mayores gastos generales de la ampliación de plazo N°s. 01, 02, 03, 04; y los reajustes del adicional N° 01, los reajustes del adicional N° 02, más los intereses legales de corresponder desde la fecha de adeudo.

CUARTO.- Al Cuarto Punto Controvertido: Se declara **INFUNDADA**, por no haberse **DECLARADO APROBADO** por consentimiento de la observación formulada por el contratista Consorcio W&Y.

QUINTO.- Al Quinto Punto Controvertido: **NO HA LUGAR** la pretensión de Consorcio W&Y, en consecuencia **ESTESE** a lo convenido por ambas partes en cuanto a la asunción de los gastos arbitrales (costos y costas), por lo que siendo que cada parte debe asumir oportunamente el costo que le correspondía, **TENGASE** por satisfecho el pago de los gastos arbitrales, con imputación de pago por subrogación; en consecuencia, **SE ORDENA** que la Municipalidad Provincial de Ambo debe reembolsar al Consorcio W&Y, la suma de S/. 6, 436. 83 (Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 83/100 Nuevos Soles).

SEXTO.- Al Sexto Punto Controvertido: Se declara **INFUNDADA**.

SÉPTIMO.- DISPÓNGASE al Secretario Arbitral remitir una copia del presente Laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su correspondiente publicación conforme a Ley.

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley.

Firmado: Teodomiro Pelayo Beteta Ventura (Presidente)

Pedro Gonzales Saldaña (Arbitro)

Berly Simón Alcántara Asencios (Arbitro).-

Berly A

Víctor W. Cisneros Alvarado
Secretario

[Signature]

[Signature]

462

VOTO DISCORDANTE

El árbitro que suscribe el presente Voto Discordante, reproduce lo expresado en los rubros: I. CUESTIÓN SOMETIDA A ARBITRAJE, II. DESIGNACIÓN E INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL, V. DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, VI. ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, VII. ALEGATOS ESCRITOS Y PLAZO PARA LAUDAR, VIII. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA CUESTIONES PRELIMNARES del Laudo emitido en la fecha en mayoría por los Árbitros: Dr. TEODOMIRO PELAYO BETETA y Dr. BERLY SIMON ALCANTARA, los mismos que corresponden a los antecedentes y resumen de las actuaciones seguidas con relación al presente proceso arbitral.

No obstante lo anterior, el árbitro que suscribe expresa su discrepancia con el sentido de lo analizado y resuelto por mayoría; en consecuencia, deja constancia de lo siguiente para fines de su correspondiente inclusión en el laudo por mayoría, incorporándose a los actuados bajo responsabilidad de la Secretaría Arbitral y notificándose a las partes.

ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, de fecha 18 de Julio del 2016, corresponde al Tribunal pronunciarse, respecto de cada uno de los puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al arbitraje para fijar, en base a la determinación conjunta de ellas, así como a los fundamentos expuestos por cada parte, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del arbitraje.

Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación de la pruebas aportadas al arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios,

pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que los ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que: *"...la actividad probatoria no pertenece a quien lo realiza, sino, por el contrario, se considera propio del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o proporcionó"*¹, siendo así, el Tribunal estima pertinente analizar la secuencia cronológica de los hechos, a través de los siguientes instrumentos:

- **CARTA N° 050-2015-YACZ/RL-W&Y**, de fecha 18 de Noviembre del 2015.

EL CONSORCIO, presenta la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO" a LA ENTIDAD.

- **CARTA N° 001-2016-MPA-ING.LIQ./JECT**, de fecha 15 de Enero del 2016.

El Ing. Jhon Edwin Criollo Timoteo, Liquidador Técnico Externo de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", realiza la elaboración, revisión, evaluación y Conformidad de la Liquidación.

- **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA**, de fecha 15 de Enero del 2016,

RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO", con las características que en la misma se indica.

- **CARTA NOTARIAL N° 001-2016-MPA/GSG**, de fecha 18 de Enero de 2016.

¹ TARAMONA H. José Rubén. Medios Probatorios en el Proceso Civil". Edic.: Rodhas 1994, pag. 35.

LA ENTIDAD notifica AL CONSORCIO, la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, por la que se RESUELVE: APROBAR la liquidación de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO" con un saldo a cargo de EL CONSORCIO hasta por la suma de S/. 86,567.83 soles.

- **CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ**, de fecha 29 de Enero de 2016.

EL CONSORCIO, presenta el INFORME DE PRONUNCIAMIENTO OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD, liquidación aprobada mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de Enero de 2016.

- **CARTA N° 002-2016-MPA-ING.LIQ/JECT**, de fecha 12 de Febrero del 2016.

El Ing. Jhon Edwin Criollo Timoteo, Liquidador Técnico Externo de la Obra "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO**", realiza el informe de revisión al INFORME DE PRONUNCIAMIENTO OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD, hecha llegar por EL CONSORCIO, a través de la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero de 2016.

- **INFORME N° 030-2016-MPA/GSG**, de fecha 12 de Febrero del 2016.

El Ing. Guzmán Gonzales Sierra, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Ambo, por los documentos de la Referencia, concluye señalando que la entidad comunica que cualquier discrepancia sobre la liquidación elaborada por la entidad debe seguir el procedimiento de Acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Liquidación elaborada por la entidad, y, la entidad se ratifica con la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA.

- **CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG**, de fecha 12 de Febrero del 2016.

El Ing. Guzmán Gonzales Sierra, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Local, en respuesta a la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero de 2016, se dirige al señor Yimber A. Cabello Zelaya, Representante Legal de EL CONSORCIO, señalando que la Liquidación de la Obra ha sido elaborada de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando a la vez a manera de conclusión:

"1.- La entidad comunica que cualquier discrepancia sobre la liquidación elaborada por la entidad debe seguir el procedimiento de Acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Liquidación elaborada por la entidad.

3.- La entidad se ratifica con la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA."

- **CARTA NOTARIAL N° 07-2016-CONSORCIO W&Y**, de fecha 01 de Marzo del 2016.

EL CONSORCIO, señala que, tras haber cursado a la entidad la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero de 2016, por el que presenta el "INFORME DE PRONUNCIAMIENTO OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD", ésta ha quedado consentida con las observaciones formuladas. EL CONSORCIO, solicita a LA ENTIDAD, se emita Acto Administrativo Resolutivo, aprobando la Liquidación de Obra elaborado por ésta, en los términos que EL CONSORCIO ha observado.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS

SEGUNDO.- EL CONSORCIO, presenta la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO" a LA ENTIDAD, a través de la **CARTA N° 050-2015-YACZ/RL-W&Y**, de fecha 18 de Noviembre del 2015.

4587

TERCERO.- El Ing. Jhon Edwin Criollo Timoteo, Liquidador Técnico Externo de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", al señalar, a través de la CARTA N° 001-2016-MPA-ING.LIQ./JECT, de fecha 15 de Enero del 2016: **"Se realiza la Recepción de obra en fecha 31 de Agosto del 2015 y, según la Ley de Contrataciones en su Artículo 211, indica que el plazo de presentación de la Liquidación de Obra es de (60) días, por parte del contratista contado a partir del día siguiente de la Recepción de Obra, por lo cual el plazo de presentación de la liquidación de obra por parte del contratista ha sido en fechas del (01/09/2015 a 30/10/2015; ... LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA FUE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL PLAZO QUE LE CORRESPONDE ELABORAR A LA ENTIDAD LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO LIQUIDACIÓN DE OBRA NO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD."**, se desprende que, la Recepción de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", se realizó el 31 de Agosto del 2015 y, según la primera parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece: **"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. ..."**, el plazo de presentación de la Liquidación de Obra debió ser entre el 01 de Septiembre del 2015 al 30 de Octubre del mismo año.

Habiendo sido el 18 de Noviembre del 2015 (fuera del plazo legal establecido) la fecha de presentación de la Liquidación de obra por parte de EL CONSORCIO, dicha fecha ya se encontraba dentro del plazo de elaboración de la Liquidación de Obra por parte de LA ENTIDAD; razón por la que, la hoy demandada lo considera como "NO PRESENTADA", haciéndosele de conocimiento ésta decisión a EL CONSORCIO, a través de la CARTA N° 013-2016-MPA/GIDEL, de

457

fecha 15 de Enero del 2016, suscrito por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local, notificado con fecha 18 de Enero del mismo año.

CUARTO.- A la no presentación de la Liquidación de Obra por parte de EL CONSORCIO en el plazo establecido (entre el 01 de Septiembre del 2015 al 30 de Octubre del mismo año), se estableció para LA ENTIDAD un plazo de sesenta (60) días siguientes para la elaboración de la Liquidación de Obra, es decir, del 31 de Octubre del 2015 al 29 de Diciembre del mismo año, en aplicación de la primera parte del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece:

“... Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. ...”.

Conforme el contenido de la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA**, de fecha 15 de Enero del 2016, por la que se resuelve aprobar la Liquidación de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO” con un saldo a cargo de EL CONSORCIO hasta por la suma de S/. 86,567.83 Soles, LA ENTIDAD, elaboró la Liquidación de Obra.

QUINTO.- La parte final del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece:

“... La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. ...”, implicando ello que LA ENTIDAD, tras la elaboración de la Liquidación de la Obra dentro del plazo establecido por el Reglamento, debe notificar la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA a EL CONSORCIO para que este se pronuncie en el plazo legal establecido.

LA ENTIDAD, a través de la **CARTA NOTARIAL N° 001-2016-MPA/GSG**, de fecha 18 de Enero de 2016, notificó la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de Enero del 2016, la misma que APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", adjuntando a la vez la Liquidación de Obra.

SEXTO.- Conforme aparece de los Medios Probatorios ofrecido por EL CONSORCIO, habiendo este recepcionado la carta notarial que se indica en el precedente numeral, a través de la **CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ**, de fecha 29 de Enero de 2016, presenta a LA ENTIDAD su "INFORME DE PRONUNCIAMIENTO DE OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD".

SÉPTIMO.- Entre los Medios Probatorios ofrecidos en el escrito de Contestación de la Demanda, se advierte que LA ENTIDAD, a través del Ing. Jhon Edwin Criollo Timoteo, Liquidador Técnico Externo de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", realiza la revisión al "INFORME DE PRONUNCIAMIENTO OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD".

El indicado Liquidador, a través de su **CARTA N° 002-2016-MPA-ING.LIQ/JECT**, de fecha 12 de Febrero del 2016, tras señalar GENERALIDADES, ANTECEDENTES, ANÁLISIS, tiene como CONCLUSIONES: **"1.- La entidad comunica que cualquier discrepancia sobre la liquidación elaborada por la entidad debe seguir el procedimiento de Acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2.- Liquidación elaborada por la entidad. 3.- La entidad se ratifica con la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA"**, señalando en sus RECOMENDACIONES: **"5.1.- Informar vía carta notarial la ratificación por la entidad de la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA al Consorcio W&Y"**.

De los mismos Medios Probatorios, se advierte asimismo que, LA ENTIDAD, a través del **INFORME N° 030-2016-MPA/GSG**, de fecha 12 de Febrero del 2016, suscrito por el Ing. Guzmán Gonzales Sierra, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Ambo, concluye: **"1.- La entidad comunica que cualquier discrepancia sobre la liquidación**

elaborada por la entidad debe seguir el procedimiento de Acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2.- Liquidación elaborada por la entidad. 3.- La entidad se ratifica con la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA.”.

OCTAVO.- LA ENTIDAD, a través de la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSC, de fecha 12 de Febrero del 2016, suscrito por el Ing. Guzmán Gonzales Sierra, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Social, teniendo como antecedente los instrumentos que se describen en el precedente numeral, señala en su numeral tercero:

“... 3.- La entidad se ratifica con la Resolución de Alcaldía N°015-2016-MPA”.

EL CONSORCIO, a través de la CARTA NOTARIAL N° 07-2016-CONSORCIO W&Y, de fecha 01 de Marzo del 2016, señala que, tras haber observado la LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADO POR LA ENTIDAD, al no existir pronunciamiento por parte de la misma, éste ha quedado consentida con las observaciones formuladas. EL CONSORCIO, solicita a LA ENTIDAD, se emita Acto Administrativo Resolutivo, aprobando la Liquidación de Obra elaborado por ésta, en los términos observados.

DEMANDA/CONTESTACIÓN DE DEMANDA

NOVENO.- EL CONSORCIO en su escrito de Demanda, en el marco de su **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL**, cuestiona: i) La aprobación “A priori” mediante Acto Administrativo de la Liquidación de Obra, elaborado por LA ENTIDAD, con saldo a cargo del contratista hasta por la suma de S/. 86,567.83 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Y 83/100 SOLES); ii) La ratificación por LA ENTIDAD de lo resuelto por la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, señalando a la vez que, dicho acto administrativo transgrede los Principios de Legalidad y el Debido Procedimiento, establecido en la norma Constitucional, en

la Ley de Procedimiento Administrativo General y, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y, **iii)** La no revisión de las observaciones formuladas por EL CONSORCIO.

Fundamenta su **SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL**, citando el cuarto y quinto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado e indicando que EL CONSORCIO presentó la observación a la Liquidación de Obra practicada por la Entidad, no pronunciándose ésta; sin embargo, lo que hizo fue ratificarse en lo resuelto por la Resolución de Alcaldía N° 015-2016-MPA por ella emitida, demandando su nulidad por transgredir los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, dejando consentir la observación formulada.

EL CONSORCIO, cita asimismo el cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el mismo que se establece: ***"Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas"***, indicando la accionante como fundamento de su SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL que, observó la liquidación practicada por LA ENTIDAD, con saldo a favor de EL CONSORCIO hasta por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES), sin embargo, LA ENTIDAD nunca se pronunció sobre tal observación, por lo que no existe documento alguno que acredite que la misma, no haya acogido las observaciones hechas por el contratista.

Finalmente la accionante señala que, la observación hecha por EL CONSORCIO a la liquidación practicada por LA ENTIDAD, ha quedado consentida y/o aprobada con las observaciones formuladas.

DÉCIMO.- Por su parte, LA ENTIDAD, al absolver la demanda, respecto de las PRETENSIONES PRIMERA y SEGUNDA de la demandante, señala: "... el

contratista incurre en error puesto que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no menciona que la respuesta a la observación realizada debe ser necesariamente un pronunciamiento mediante una resolución. ...".

Tras citar textualmente el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD, al absolver la demanda en su contra, señala: "... en ningún extremo señala que se debe emitir una resolución, sino que se debe "pronunciarse", y se deberá hacer "por escrito". ...mi representada procedió a realizar la liquidación de la obra, lo cual es aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 015-2016-A-MPA, pero mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, el representante legal del COSROCIO W&Y presenta informe de pronunciamiento observando la liquidación de la obra por la Entidad. Al respecto, y conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "pronunciarse" y "Por escrito", mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de Febrero del 2016 emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Ambo, se da respuesta a la CARTA N° 001-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, pronunciándose con INFORME N° 030-2016MPA/SGS, de fecha 12 de febrero del 2016, en la cual se RATIFICA A FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-MPA sustentando que la liquidación de obra ha sido elaborada de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicha CARTA NOTARIAL ha sido notificado al Ing. YIMBER A. CABELLO ZELAYA-Representante Legal del CONSORCIO W&Y y recepcionada por YACZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L."

LA ENTIDAD señala en su contestación de demanda que ha cumplido con la norma legal...por lo que no ha vulnerado el Principio de Legalidad ni el Debido Procedimiento señalado por el demandante.

Tras describir los Principios de Legalidad y del Debido Procedimiento, LA ENTIDAD señala en su escrito de demanda: "... mi representada ha sido

respetuoso de los lineamientos procedimentales que ha establecido la Ley, por lo que la sustentación en la afectación de los principios de Legalidad y debido procedimiento, y por ende existe vicios de nulidad son infundadas.”.

LA ENTIDAD fundamenta asimismo su absolución de demanda citando el Artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo General señalando: “... Como se puede, revisar de la norma legal, los actos administrativos serán las declaraciones de las entidades, la cual no necesariamente debe recaer en una resolución conforme pretende imponer el demandante, sino que debe contener o debe producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones y derecho de los administrados dentro de una situación concreta ... no advirtiéndose vicios ni causales de nulidad que puedan estar sustentadas en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, ...”.

Señala asimismo LA ENTIDAD: “... respecto a que se declare la aprobación por consentimiento de la observación formulada por el contratista CONSORCIO W&Y mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, es de indicar que, la misma no tiene sustento legal, ya que como se ha indicado precedentemente, mi representada ha dado respuesta a la observación realizada por el demandante, mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/SGS, de fecha 12 de Febrero del 2016, la cual contiene el INFORME N° 030-2016-MPA/SGS, de fecha 12 de Febrero del 2016, en la cual existe el pronunciamiento de la entidad, la cual es la RATIFICACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DEALCALDÍA N° 015-2016-MPA.”.

Finalmente la demandada argumenta en su absolución de demanda, señalando: “... El demandante confunde en que se debe responder siempre con resolución, lo cual la norma legal no regula en ese sentido, por tanto no está prohibido emitir pronunciamiento mediante otra forma distinta a la resolución, más si consideramos que un acto administrativo debe contener una declaración de la entidad, y que produzca efectos jurídicos en la situación del administrado, lo cual en el presente caso se ha dado mediante la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/SGS, de fecha 12 de Febrero del 2016. Por consiguiente, es totalmente infundada aprobar por

consentimiento la observación formulada por el contratista sobre la liquidación de obra realizada por LA ENTIDAD, toda vez que la CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ (que contiene informe de observación) ha sido respondido dentro del plazo legal de 15 días establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo así con la citada norma legal. Por tanto esta pretensión principal de aprobación por consentimiento deviene en INFUNDADA, por no existir consentimiento alguno."

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto de la **SEGUNDA PRETENSION SUBORDINADA**, EL CONSORCIO demanda a LA ENTIDAD se practique una nueva liquidación, tomando en cuenta los antecedentes de la observación formulada por este, mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, por cuanto en la liquidación practicada por la Entidad, no se consideran los Reajustes del adicional N° 01; Reajustes del Adicional N° 02; Mayores Gastos Generales de la ampliación N° 01; Mayores Gastos Generales de la ampliación N° 02; Mayores Gastos Generales de la ampliación N° 03; Mayores Gastos Generales de la ampliación N° 04; Mayores Gastos Generales de la ampliación N° 05; Intereses Legales; Otros gastos no considerados.

EL CONSORCIO, demanda asimismo, se tome en cuenta la CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero de 2016, para la nueva Liquidación, por cuanto, LA ENTIDAD nunca se pronunció conforme a lo que ordena el RLCE a la observación formulada por el Contratista, pese a que el Artículo 211° del Reglamento establece que, cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, este deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

Por la **TERCERA PRETENSIÓN**, EL CONSORCIO solicita: **"Se ordene a la Entidad demandada, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista CONSORCIO W&Y la suma de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES), según observación**

450

formulada por el contratista CONSORCIO W&Y mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero de 2016, observación que ha quedado consentida." Argumenta EL CONSORCIO: "... dentro de los quince (15) días de recibido la liquidación de obra que fue elaborada por la Entidad, OBSERVO con saldo a favor del Contratista por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES) sin embargo la Entidad nunca se pronunció respecto a la observación formula por el recurrente, por lo tanto no ha cumplido con lo dispuesto en la norma ni en el contrato, por lo que de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, la Administración Publica por su inacción debe asumir las consecuencias de su inoperancia y desconocimiento, ya que por su silencio y el incumplimiento de seguir el procedimiento de liquidación de obra, no puede perjudicar a los administrados; en consecuencia la falta de pronunciamiento de la Entidad, en la forma que la ley ha establecido y dentro del plazo de quince (15) días, trae consigo el consentimiento y aprobación de la liquidación con las observaciones formuladas, entendiendo que esta norma es aplicada a ambas partes dentro del plazo establecido, de tal manera reitero, que el carácter de la norma la observación formulada por el contratista, sin un pronunciamiento de acorde a Ley se encuentra aprobada por mandato expreso de la Ley, debiendo reconocer todo sus efectos legales como es el pago al contratista por el monto de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES). Conforme a la Carta de Pronunciamiento y Observación a la Liquidación de obra y sus anexos de donde vislumbra los conceptos por las cuales la Entidad está en la obligación de pagar."

DÉCIMO SEGUNDO.- LA ENTIDAD, en su escrito de contestación de demanda expresa que se debe declarar infundada la pretensión de realizar nueva liquidación, toda vez que la observación formulada mediante CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, ha sido materia de pronunciamiento mediante

CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/SGS, de fecha 12 de Febrero del 2016, la misma que contiene la CARTA N° 002-2016-MPA-ING.LIQ./JECT, en la cual se analiza de manera detallada la liquidación de la obra realizada por LA ENTIDAD, así como la observación formulada.

Finalmente, LA ENTIDAD expresa en su contestación de demanda que, la pretensión solicitada por el demandante, respecto a que se pague la suma de S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y 43/100 SOLES), es totalmente infundada, toda vez que la observación del demandante contenida en su CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ de fecha 29 de Enero del 2016 carece de sustento técnico y legal, toda vez que la liquidación presentada es totalmente ajeno a la realidad documentaria. Indica asimismo que de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 166-2016-MPA-PSMS-SGSL, el Liquidador Externo aplicó la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, conforme el Acta de Conciliación N° 060-2015, en la cual el contratista acepta la propuesta de mi representada. En tal sentido, la liquidación de obra efectuada por mi representada contenida en la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-MPA, se encuentra ajustada a derecho y conforme a las normativas legales al caso. En consecuencia, las pretensiones del demandante son INFUNDADAS.

DÉCIMO TERCERO.- Respecto a la **CUARTA PRETENSIÓN**, EL CONSORCIO señala que LA ENTIDAD está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO W&Y, la suma de S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Soles) por concepto de costas y/o honorarios del árbitro en el presente proceso arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidades de la Municipalidad Provincial de Ambo, puesto que al haberse emitido la Resolución N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de Enero del 2016, de manera temeraria y anticipada, transgrediendo el principio de legalidad y debido procedimiento, aprobando la liquidación de obra en su primera oportunidad.

En cuanto a su **QUINTA PRETENSIÓN**, EL CONSORCIO indica que LA ENTIDAD está en la obligación de pagar al Contratista Consorcio W&Y, la suma de S/. 8,000.00 (Ocho mil y 00/100 Soles) más intereses, por concepto de costos...

448

para la defensa y hacer valer mis derechos ante la Resolución N° 015-2016-A-MPA. Demás que expone.

DÉCIMO CUARTO.- Respecto a la **CUARTA y QUINTA PRETENSIÓN**, LA ENTIDAD describe en la contestación de su demanda que, de conformidad con el numeral 1) del Artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, los costos del proceso arbitral deberán ser asumidos completamente por el demandante, toda vez que su demanda carece de fundamentos fácticos y legales que lo amparen. Los intereses legales deben seguir la suerte del principal, debiendo el demandante cancelar a la entidad respecto a esta pretensión hasta la cancelación. Finalmente solicita, se condene al demandante al pago de costas y costos del proceso que se incurre, debiendo reembolsar a la entidad, en lo que corresponda.

ANÁLISIS DE DERECHO

DÉCIMO QUINTO.- A la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO", elaborada por LA ENTIDAD, en el caso sub examine materia de controversia, de los Puntos Controvertidos fijados en Audiencia de fecha 18 de Julio del 2016, se advierte marcados puntos en cuestión, como son: **i)** La emisión de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de Enero del 2016, que aprueba la indicada liquidación, notificada a EL CONSORCIO, a través de la CARTA NOTARIAL N° 001-2016-MPA/GSG, de fecha 18 de Enero del 2016; **ii)** La ratificación por parte de LA ENTIDAD en la resolución que se indica en el precedente inciso, a través de la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de Febrero del 2016 y demás que deviene.

Lo señalado en tales incisos, serán materia de análisis fáctico y legal, a fin de determinar si el contenido del escrito de demanda y la posición de la demandada, traducido en los Medios Probatorios, se encuentran arreglada a ley,

lo que permitirá al Tribunal Arbitral, teniendo como base los puntos controvertidos fijados, emitir el Laudo conforme a las normas de contrataciones y demás de aplicación supletoria conforme al Derecho.

Por la naturaleza de los puntos en cuestión, la controversia se enmarcará a lo normado en el Artículo 211°, CAPÍTULO VII OBRAS del TÍTULO III EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando el análisis específicamente en lo establecido en el segundo, cuarto y quinto parágrafo del referido artículo:

"Artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.”. (El énfasis en añadido)

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR LA NULIDAD Y/O INEFICACIA EN TODO SUS EXTREMOS, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, SU FECHA 15 DE ENERO DE 2016, QUE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO-PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO”, CON SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA POR UN MONTO DE S/. 86,567.83 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES 00/100 SOLES).

DÉCIMO SEXTO.- Habiendo sido el 18 de Noviembre del 2015 el día que EL CONSORCIO presentó la Liquidación de obra, dicha fecha estaba fuera del plazo establecido; consecuentemente, ya se encontraba dentro del plazo de elaboración de la Liquidación de Obra por parte de LA ENTIDAD, considerándola ésta como “NO PRESENTADA”, haciéndosele de conocimiento tal decisión a EL CONSORCIO, a través de la CARTA N° 013-2016-MPA/GIDEL, de fecha 15 de Enero del 2016, conforme se advierte de autos. Este hecho implicó la elaboración de la Liquidación de Obra por parte de la Municipalidad Provincial de Ambo, en atención a lo establecido en la primera parte del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que

prescribe: **"Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista."**

Tras la elaboración de la liquidación, la Municipalidad Provincial de Ambo, notificó al Consorcio, a fin de que éste se pronuncie en el plazo legal establecido, esto, de conformidad a lo establecido en la segunda parte del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: **"... La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes."**, notificación que se acredita con la **CARTA NOTARIAL N° 001-2016-MPA/GSG**, de fecha 18 de Enero de 2016, la misma que adjunta la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA**, que **APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO"**, recepcionado por EL CONSORCIO con fecha 18 de Enero del 2016, conforme se describe en el numeral QUINTO del presente análisis.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La Liquidación de Obra que se indica en el precedente numeral, por su naturaleza, tiempo y espacio, no correspondía su aprobación con acto administrativo resolutivo, por estar este en proceso de notificación a EL CONSORCIO, la emisión del pronunciamiento por parte de éste y, demás que sigue hasta su aprobación, por así establecerlo la norma de Contrataciones del Estado, además que, desnaturaliza el Acto propiamente Administrativo, que el Derecho especializado lo define y norma como las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta².

La **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA**, que **APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO"**, no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 3° de la

² Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 1°, 1.1.

Ley del procedimiento Administrativo General N° 27444, por cuanto carece de: i) **Objeto o contenido**, ya que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; ii) **Motivación**, por cuanto el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, y, iii) **Procedimiento regular**, toda vez que, antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. La carencia de los mencionados requisitos, evidencia asimismo por parte de LA ENTIDAD, que tiende hacia lo arbitrario, por cuanto abusa del ejercicio de la potestad discrecional reconocida por ley.

Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada³.

Consecuentemente, al haberse forzado la emisión del acto administrativo, contraviniendo los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento e incurrir en uno de los vicios que causan su nulidad de pleno derecho que establece el **Artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, que es la de contravenir a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, deviene en nulo e ineficaz, careciendo de todo efecto jurídico respecto a la materia aprobada.

De conformidad a lo establecido en la segunda parte del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma solo dispone a que la Entidad debe notificar la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro del plazo legal establecido.

³ Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. STC 8495-2006-PA/TC

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE SE DECLARE LA APROBACIÓN POR CONSENTIMIENTO DE LA OBSERVACIÓN FORMULADA POR EL CONSORCIO MEDIANTE CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016, OBSERVACIÓN HECHA A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, PRACTICADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO.

DÉCIMO OCTAVO.- En aplicación del cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "... *Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.*", EL CONSORCIO se pronuncia observando la Liquidación de Obra presentada por la Municipalidad Provincial de Ambo, a través de la CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, de 29 de Enero del 2016, recepcionado por LA ENTIDAD en la misma fecha.

En aplicación del mismo párrafo del acotado artículo y norma, corresponde en este caso, a la hoy demandada, Municipalidad Provincial de Ambo, pronunciarse dentro de los quince días de haber recibido tal observación; de no haberlo hecho, conforme describe la norma, se tendrá por aprobada la Liquidación de la Obra con las observaciones formuladas por EL CONSORCIO.

Se advierte de autos que, la Municipalidad Provincial de Ambo, ante el PRONUNCIAMIENTO presentando por EL CONSORCIO, OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, lo que hace, a través de la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG de fecha 12 de Febrero del 2016, es ratificarse con lo resuelto en la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA**, que **APRUEBA** LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO".

DÉCIMO NOVENO.- Estando a lo que se describe en el numeral DÉCIMO SÉPTIMO del presente análisis, la ratificación descrita en el precedente numeral, deviene asimismo en nulo e ineficaz, carente de todo efecto jurídico

por suceder de un forzado acto administrativo en igual condición legal; además que, como consecuencia de tal "ratificación", LA ENTIDAD, prescinde del pronunciamiento propiamente dicho exigida por ley para estos casos, vulnerando lo establecido en el cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "... **ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; ...**". Debe precisarse asimismo, lo siguiente: i) El pronunciamiento -obviamente, que no acoge las observaciones-, debe manifestarse por escrito en el plazo previsto, de conformidad a lo establecido en la primera parte del quinto párrafo del referido artículo: "**En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. ...**"; ii) Si así correspondiere, tal "ratificación" debió resolverse por otro acto administrativo de igual jerarquía, mas no con una carta cursada notarialmente; iii) El segundo párrafo del Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, las funciones de su competencia, con excepción de la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento; por lo que, el Titular de la Entidad puede delegar en otro funcionario la emisión del pronunciamiento sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra, toda vez que dicha facultad no se encuentra comprendida entre los supuestos en los que la delegación está prohibida. El pronunciamiento de la Entidad sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra debe realizarse expresa y formalmente, a través del Titular de la Entidad o del funcionario a quien este haya delegado tal facultad.

Se advierte de los Medios Probatorios ofrecidos por la demandada en este extremo que, al emitirse la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG de fecha 12 de Febrero del 2016, por la que el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Ambo se ratifica con lo resuelto en la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA que APRUEBA la Liquidación de la Obra "Mejoramiento de los Servicios Municipales de la Municipalidad de Ambo Provincia de Ambo-Huánuco", ésta no adjunta instrumento alguno que acredita se le haya delegado al indicado funcionario la facultad de pronunciarse sobre la liquidación de obra,

por lo que, estando establecido que el pronunciamiento de la Entidad sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra debe realizarse expresa y formalmente a través del Titular de la Entidad o del funcionario a quien este haya delegado tal facultad, la demandada vulnera lo estipulado en el Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado, refrendado este en el mismo número de artículo de su Reglamento; consecuentemente, la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de Febrero del 2016, a lo resuelto en el forzado acto administrativo deviene asimismo en nulo e ineficaz, sin efecto jurídico alguno, además que este acto administrativo carece de los requisitos para su validez establecido en el Artículo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444: ***“... Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.”.***

VIGÉSIMO.- A lo indicado en el último párrafo del precedente numeral, la CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG no puede significar y/o ser un pronunciamiento exigido en el cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ***“... ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; ...”***, más aún cuando erróneamente LA ENTIDAD, en el inciso b.1.3 de su escrito de contestación de la Demanda, señala: ***“... Al respecto, y conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “pronunciarse” y “Por escrito”, mediante CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG, de fecha 12 de Febrero del 2016 emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Ambo, se da respuesta a la CARTA N° 001-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, pronunciándose con INFORME N° 030-2016MPA/SGS, de fecha 12 de febrero del 2016, en la cual se RATIFICA A FAVOR DE LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-MPA sustentando que la liquidación de obra ha sido elaborada de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ...”.*** Menos puede

considerarse "pronunciamiento" al **INFORME N° 030-2016MPA/SGS**, de fecha 12 de febrero del 2016 por ser este un acto de administración interna, aun fuere documento adjunto a la **CARTA NOTARIAL N° 005-2016-MPA/GSG**, de fecha 12 de Febrero del mismo año.

Es importante señalar que cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de recibida la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada con las observaciones formuladas.

En virtud de lo expuesto, la liquidación de obra queda consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Sobre el particular, debe indicarse que el hecho que una liquidación de obra quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme; es decir, se presume⁴ que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

En esa medida, el consentimiento de la liquidación de obra implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observó dentro del plazo establecido⁵.

Tras el análisis realizado y, conforme se describe en los precedentes numerales en base a los Medios Probatorios ofrecidos por las partes en el presente proceso arbitral, se evidencia que LA ENTIDAD inobservó lo establecido en el cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: **"... Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas."** El extremo de la inobservancia del párrafo descrito por parte

⁴ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésimo Tercera Edición, "presunción", en su segunda acepción, significa "Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad que sea probado." <http://dle.rae.es/?id=U7ZEVjW>

⁵ **OPINIÓN N° 196-2015/DTN-OSCE**, de fecha 31 de Diciembre del 2015

de LA ENTIDAD, es que ésta, ante la observación a la Liquidación de Obra por parte de EL CONSORCIO, no cumplió con pronunciarse en el plazo y forma legal fijado, mucho menos cumplió con manifestarlo por escrito en el mismo plazo, como se establece en la primera parte del quinto párrafo del referido artículo: ***"En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. ..."***.

En consecuencia, la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO", debe tenerse por aprobado con las Observaciones formuladas por EL CONSORCIO, el mismo que se pronunció observando la Liquidación de Obra, a través de la CARTA N° 01-2016-CONSORCIOW&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero del 2016, suscrito por don Yimber A. Cabello Zelaya, representante Legal del Consorcio W&Y, recepcionado por LA ENTIDAD en la misma fecha, conforme se dispone en la última parte del cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ***"... Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas."*** (El énfasis en añadido)

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN TOMANDO EN CUENTA LOS ANTECEDENTES DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO W&Y, MEDIANTE CARTA N° 01-2016 CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, DEL 29 DE ENERO DEL 2016.

VIGÉSIMO PRIMERO.- El presente punto controvertido fijado por el Tribunal, que es la SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA del demandante, se subsume al análisis del SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO, específicamente a lo que se indica en el último párrafo del precedente numeral, por lo que, la Municipalidad Provincial de Ambo debe practicar una nueva Liquidación de Obra con las

438

observaciones formuladas por el Contratista CONSORCIO B&Y, hechas llegar a través de la CARTA N° 01-2016 CONSORCIO W&Y/RL-YACZ, del 29 de Enero del 2016 por haber quedado consentida tales observaciones, por así disponerse en la última parte del cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE SE ORDENE A LA ENTIDAD, PAGUE EL MONTO POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE EL CONSORCIO LA SUMA DE S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES), SEGÚN OBSERVACIÓN FORMULADA POR EL CONSORCIO MEDIANTE CARTA N° 01-2016-CONSORCIO W&Y/RL-YACZ DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016, OBSERVACIÓN QUE HA QUEDADO CONSENTIDA.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Conforme es de verse de los medios probatorios ofrecido por la demandante, la CARTA N° 01-2016-CONSOSRCIOW&Y/RL-YACZ, de fecha 29 de Enero del 2016, suscrito por el señor Yimber A. Cabello Zelaya, Representante Legal del Consorcio, adjunta EL INFORME DE PRONUNCIAMIENTO OBSERVANDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, ELABORADO POR LA ENTIDAD, el mismo que contiene: GENERALIDADES, ANTECEDENTES, SUSTENTO LEGAL, ANÁLISIS TÉCNICO y, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, siendo el ANEXO N° 05 la LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, la misma que contiene información detallada en el rubro AUTORIZADO Y PAGADO, SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, ADELANTOS, MULTA POR ATRASO DE OBRA y, denotándose en el RESUMEN DE SALDOS el monto de S/. 200.690.43 (Doscientos mil, seiscientos noventa y 43/100 Soles) como TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA, incluido IGV.

Como es de advertirse del análisis del SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO, la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO", debe tenerse por aprobado con las Observaciones formuladas por EL CONSORCIO,

437

como lo dispone en la última parte del cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "... **Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.**". Consecuentemente, no habiéndose pronunciado la Municipalidad Provincial de Ambo ante la observación presentado por EL CONSORCIO, debe la demandada aprobar la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO" con las observaciones formuladas por EL CONSORCIO, trayendo esto consigo el pago POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE EL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES).

VIGÉSIMO TERCERO.- Debe precisarse que, el hecho que una liquidación de obra quede consentida **genera efectos jurídicos y económicos**. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme; es decir, se presume que su no observación -en este caso el no pronunciamiento a la observación-, dentro del plazo establecido, implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda. En esa medida, los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes, de corresponder.⁶

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:

⁶ OPINIÓN N° 104-2013/DTN

436

DETERMINAR SI CORRESPONDE DISPONER QUE LA ENTIDAD ASUMA LOS GASTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL ESTO ES GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, DEBIENDO ORDENAR QUE SE REEMBOLSE A EL CONSORCIO LA SUMA DE S/. 12,873.67 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 67/100 SOLES).

VIGÉSIMO CUARTO.- Disponer que el Consorcio W&Y y la Municipalidad Provincial de Ambo, cada uno y directamente asuma los gastos arbitrales que les correspondía sufragar (50% a cada uno de ellas).

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE DISPONER A QUE LA ENTIDAD ASUMA LOS COSTOS (HONORARIOS DE ABOGADOS E INGENIEROS ASESORES) PARA LA DEFENSA EN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL, QUE ASCIENDE LA SUMA DE S/. 8,000 00 (OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MÁS LOS INTERESES LEGALES HASTA LA FECHA DE CANCELACIÓN.

VIGÉSIMO QUINTO.- Cada una de las partes deberá asumir los gastos de asesoría legal en que hubieran incurrido a raíz del presente arbitraje.

LAUDO

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo indicado en los numerales 52.1 y 52.2 del Artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la competencia otorgada a los tribunales arbitrales para resolver las controversias producidas durante el procedimiento de liquidación de obra, el presente laudo⁷ contiene las disposiciones necesarias que resuelven

⁷ El artículo 231 del Reglamento establece que "El laudo es definitivo e inapelable, tiene un valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones deberán ser notificados a través del SEACE, (...)". (El subrayado es agregado).

la controversia, encontrándose establecido claramente las condiciones u obligaciones que las partes deben cumplir para ello⁸.

Estando a las consideraciones expuestas en los análisis precedentes y al Derecho aplicable, dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral debe laudar conforme a lo siguiente:

PRIMERO.- Al Primer Punto Controvertido, **FUNDADA** la PRIMERA PRETENSIÓN de la Demandante, por lo que, **DECLÁRESE** la **NULIDAD** de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 015-2016-A-MPA, de fecha 15 de Enero del 2016 que APRUEBA la Liquidación de la Obra "Mejoramiento de los Servicios Municipales de la Municipalidad de Ambo Provincia de Ambo-Huánuco".

SEGUNDO.- Al Segundo Punto Controvertido, **FUNDADA** la SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL de la Demandante, por lo que, la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO", debe tenerse por aprobado con las Observaciones formuladas.

TERCERO.- Al Tercer Punto Controvertido, **FUNDADA** la SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA de la Demandante, por lo que, la Municipalidad Provincial de Ambo debe practicar una nueva Liquidación de Obra con las observaciones formuladas por el Contratista.

CUARTO.- Al Cuarto Punto Controvertido, **FUNDADA** la TERCERA PRETENSIÓN de la Demandante, por lo que, la Municipalidad Provincial de Ambo, considerando lo resuelto en el precedente numeral debe efectuar el pago POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE EL CONTRATISTA LA SUMA DE S/. 200,590.43 (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES).

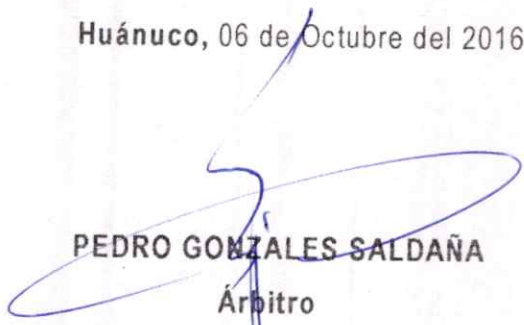
⁸ OPINIÓN N° 019-2013/DTN-OSCE, de fecha 08 de Febrero del 2013

434

QUINTO.- Al Quinto Punto Controvertido, **INFUNDADA** la CUARTA PRETENSIÓN, por lo que, el Consorcio W&Y y la Municipalidad Provincial de Ambo, cada uno y directamente asuma los gastos arbitrales que les correspondía sufragar (50% a cada uno de ellas).

SEXTO.- Al Sexto Punto Controvertido, **INFUNDADA** la QUINTA PRETENSIÓN.

Huánuco, 06 de Octubre del 2016.


PEDRO GONZALES SALDAÑA

Árbitro


Victor W. Cisneros Alvarado

Secretario